

1501393-63.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... fls. 124/126. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial militar Luiz Flavio Fantin Pereira, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Esplanada, onde ocorre intenso trafico de drogas, quando visualizaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501393-63.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/001213

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251663/2022 - 02º D.P. PIRACICABA, 27426398 - 02º D.P. PIRACICABA, 2251663 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DOS SANTOS VICENTE

Réu Preso

Aos 13 de dezembro de 2022, às 16:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: GUSTAVO DOS SANTOS VICENTE - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM LUIZ FLAVIO FANTIN PEREIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM GUSTAVO DOS SANTOS ANJOS - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PM LUIZ FLAVIO FANTIN PEREIRA.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM GUSTAVO DOS SANTOS ANJOS, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM

GUSTAVO DOS SANTOS ANJOS, o que foi homologado pela MMª. Juíza. Após, o réu GUSTAVO DOS SANTOS VICENTE foi devidamente interrogado. O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. Então, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "GUSTAVO DOS SANTOS VICENTE, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 104/107. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 132/133), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 136/137), sendo a denúncia recebida (fls. 139/141). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografia de fls. 46, pelo laudo de constatação de fls. 14/16 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 124/126. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial militar Luiz Flavio Fantin Pereira, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Esplanada, onde ocorre intenso trafico de drogas, quando visualizaram o acusado sentado, o qual, ao ver a viatura, tentou se evadir rapidamente, levantando suspeitas, mas a equipe conseguiu detê-lo. Realizada revista pessoal, foi localizado dentro de sua cueca uma caixa de fósforo contendo em seu interior 19 pedras de crack, embaladas para venda, bem como, no bolso de sua blusa, a quantia de vinte reais. Indagado, o acusado não apresentou justificativa da origem do dinheiro apreendido, bem como mostrou-se nervoso com o encontro dos entorpecentes em sua cueca. Destacou que o local é bem próximo da escola estadual E.E. Alcides Guidetti Zagatto e, em pesquisas, verificaram que o acusado estava evadido do CDP de Piracicaba desde 06/09/22 No mesmo sentido foram as palavras do policial militar Gustavo Dos Santos Anjos, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que estava evadido do sistema semiaberto e estava morando na rua, sendo usuário de drogas. Disse que os vinte reais era proveniente de um serviço de jardinagem que fizera no dia anterior e que as pedras que trazia consigo era para seu próprio uso. Alegou que estava parado na calçada para guardar as drogas no seu tenis, sendo que tentou sair do local ao ver a viatura. Assim, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, é certo que os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que o acusado estava em local já conhecido como ponto de trafico, tentou se evadir ao avistar a viatura e, em seu poder, porem apreendidos os entorpecentes descritos na denuncia, quais sejam, 19porções de crack, embaladas individualmente, prontas para a venda, sendo que os entorpecentes estavam muito bem escondidos dentro de uma caixa de fosforo dentro de sua cueca, próximo da virilha, não tendo como prevalecer a alegação do acusado que havia ali parado apenas para guardar as drogas no tênis, e que as colocou na cintura ao ver os policiais. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu a Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça nos termos do voto do Relator Ministro Ribeiro Dantas no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.096.763/TO, julgado em 14/06/2022 e publicado no DJe de 20/06/2022, do qual se extrai o seguinte trecho: Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ainda nesse sentido: Segundo entendimento

reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (STJ – HC n. 395.325/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 18/05/2017, DJe de 25/05/2017). (Grifei) Por fim, tem-se que a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06 restou também plenamente caracterizada e comprovada, tanto pela prova oral quanto pelo mapa acostado as fls 104, restando demonstrado que o local onde o acusado praticava o tráfico ficava nas proximidades da E.E. Alcides Guidetti Zagatto, Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, verifica-se que o réu ostenta condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de drogas (autos nº 0015930-78.2014.8.26.0451 – fls. 109), razão pela qual a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, há agravante da reincidência (autos nº 1501457-78.2019.8.26.0451 – fls. 109/110; 1501870-91.2019.8.26.0599 – fls. 110; 1509579-05.2020.8.26.0451 – fls. 110/111), devendo, assim, a pena ser agravada. Na terceira fase, inaplicável o art. 33, §4º da Lei de Drogas, ante a reincidência do acusado e pelo fato de ostentar ele condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico, o que demonstra que, de longa data, ele faz desta prática seu meio de vida. Ainda na terceira fase, tendo em vista que o delito de tráfico foi praticado nas dependências de estabelecimento de ensino, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, de modo que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Luiz Flávio, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro, em virtude da grande incidência do tráfico de drogas. Em determinado momento, avistaram o réu, que se levantou e começou a caminhar na direção contrária da viatura. Diante disso, efetuaram a abordagem e, em busca pessoal, encontraram R\$ 22,00 em poder do réu. Além disso, dentro da cueca do acusado, localizaram uma caixa de fósforos contendo as porções de crack. O acusado disse que era usuário de drogas e tinha ganhado os entorpecentes. Ele disse que estava morando na rua. Em consulta aos sistemas, verificaram que o acusado estava evadido do sistema prisional. Não conhecia o réu antes dos fatos. Encontraram duas notas de R\$ 10,00 em poder do réu. Ele nada disse a respeito da origem do dinheiro. O local fica próximo de uma escola estadual. O réu, em interrogatório, declarou que estava evadido do sistema prisional e vivendo em situação de rua. É usuário de crack. Um dia antes dos fatos, tinha feito um serviço de poda de galhos de árvores e limpeza de calçada e ganhou um pouco de dinheiro. No dia seguinte, foi até o ponto de tráfico e comprou as drogas para seu consumo pessoal, ficando com R\$ 22,00. Enquanto ia embora, parou um pouco para colocar as drogas na meia. Nesse momento, a viatura apareceu e o abordou. Disse aos Policiais que era usuário e falou para eles a forma como obteve o dinheiro. Não estava vendendo drogas, tanto que foi abordado fora do ponto de tráfico. Recebeu R\$ 65,00 pelo serviço. Comprou 19 porções de crack, pois, como já tinha comprado outras porções em outras ocasiões, pagou por 10 porções e ficou devendo para o traficante. Não conhecia os Policiais que fizeram a sua prisão. Desde o dia que saiu da prisão, usou drogas todos os dias (mais de 20 ou 30 pedras por dia). Pagava pelas pedras fazendo serviços esporádicos na rua ou, então, usava as drogas de maneira compartilhada com outros usuários. Portanto, Excelência, o acusado nega a prática do tráfico de drogas. Sua negativa deve ser considerada um elemento

probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitera-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO

EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001). Requer-se, também, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, caso não se proceda à absolvição do acusado, de rigor reconhecer-se que o aumento gerado pelo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastado, eis que a circunstância prevista no referido dispositivo legal não restou devidamente configurada na hipótese em testilha. Isso porque, para a incidência da majorante em comento, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para determinado mercado consumidor. Assim, a causa de aumento da pena somente tem lugar quando o agente, nos locais ali especificados, encontra-se com o intuito de conseguir clientela ou ampliar seu comércio de tóxicos, difundindo o vício entre doentes, estudantes, presidiários ou pessoas que frequentam um determinado evento, o que não ocorreu nesse caso. Nestes termos, o simples fato de o denunciado ter sido surpreendido próximo a uma escola (art. 40, III) não configura, por si só, a incidência da causa de aumento. Entendimento

contrário traduzir-se-ia em responsabilização objetiva, vedada em nosso sistema penal. Isso porque a assunção deste tipo de responsabilidade em matéria penal importa lesão a um sem-número de princípios constitucionais, como o princípio da culpabilidade individual, a individualização da pena, a proporcionalidade das reprimendas e, no limite, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Assim, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para aquele mercado consumidor. Desta forma, diante da flagrante impropriedade da prova em demonstrar a configuração da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, ela deve ser afastada. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

Então, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

GUSTAVO DOS SANTOS VICENTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de setembro de 2022, por volta de 12h, na Rua Professor Benedito Rodrigues de Moraes, nº 282, Bairro Jardim Esplanada, nas imediações da Escola Estadual "Alcides Guidetti Zagatto", nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 19 (dezenove) porções de cocaína na forma de "crack", pesando cerca de 1,2g (um grama e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, situado nas imediações da Escola Estadual "Alcides Guidetti Zagatto", já conhecido ponto de tráfico, quando avistaram o acusado, o qual, ao avistar a viatura, tentou se evadir rapidamente, porém foi contido e abordado pelos agentes públicos. Em busca pessoal, foram localizados na posse de GUSTAVO, especificamente no interior de uma caixa de fósforos que estava em sua veste íntima, dezenove porções de "crack" e, no bolso de sua blusa, a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/06 (fls. 133) e apresentou defesa preliminar (fls. 136/137), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 139/141).

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pela fotografia de fls. 46, pelo laudo de exame químico-toxicológico de

fls. 124/126, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa, pois, tendo se valido do direito de permanecer em silêncio por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), o réu admitiu, em juízo, a posse da droga.

Resta apreciar se era destinada ao tráfico, como consta da denúncia, ou ao consumo próprio, como alega o réu.

Ele afirmou que estava evadido do semiaberto e morava na rua. Afirmou que caiu no vício do crack e estava fumando e ficando na rua até quando desse. Declarou que tinha feito um serviço numa casa, de poda e limpeza da calçada, pelo que recebeu R\$ 65,00. Afirmou que saiu dali, com dinheiro no bolso, mas parou num prédio abandonado e adormeceu, porque estava há dias sem dormir. Asseverou que, no dia seguinte, cedo, foi ao ponto de tráfico, pegou 19 pedras e ficou com vinte reais, pois ia passar no bar para comprar isqueiro e lata de refrigerante para usar a droga. Alegou pagou nove pedras em dinheiro e ficou devendo o restante. Disse que, na saída, realmente se abaixou para guardar a droga no tênis, mas viu viatura, levantou-se rapidamente e tentou sair andando. Afirmou que só teve tempo de por a caixa de fósforos na cintura e acabou sendo abordado. Sustentou que ficou foragido do dia 06 ao dia 14 e só dormiu aquela noite, porque estava muito cansado, nos outros dias, ficou acordado sem dormir, usando muita droga, de vinte ou trinta pedras por dia. Disse que, na rua, batem palma nas casas para fazer serviços e as pessoas pagam. Ademais, reúnem-se com outros usuários, cada um tem um pouco de drogas e fazem uso de drogas juntos.

O policial militar Luiz Flávio relatou que, no dia dos fatos, estavam no bairro Jardim Esplanada, onde há grande incidência de tráfico. Informou que avistaram o réu, que estava sentado e, ao notar a viatura, levantou-se rapidamente e saiu na direção contrária, razão pela qual fizeram a abordagem. Atestou que, com ele, apreenderam R\$ 20,00 e, nas vestes íntimas, uma caixa de fósforos, com porções de crack. Aduziu que o réu afirmou que morava na rua, não tinha endereço fixo e tinha ganhado aquelas porções. Após, fizeram consulta e constataram que era evadido do sistema prisional. Acrescentou que os fatos se passaram ao lado de uma escola municipal.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Gustavo, ouvido a fls. 05.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais militares não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais militares é tão válida quanta outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665).

A quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de

Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).
"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Some-se a isso que o réu não logrou justificar como teria adquirido as dezenove porções encontradas em seu poder: disse que tinha recebido R\$ 65,00, adquiriu dezenove porções e ficou com R\$ 20,00 para comprar isqueiro e latinha. Porém, considerando que cada porção de "crack" é vendida a R\$ 5,00, segue-se que a compra não ficou adequadamente justificada.

Questionado, chegou a afirmar que pagou só nove pedras e ficou devendo o restante. Mas, se ainda tinha R\$ 20,00 consigo, essa assertiva sequer é verossímil. De qualquer modo, o réu não demonstrou ter renda para sustentar vício tão caro, se, como alegou, chegava a usar até 30 pedras de "crack" por dia. Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Na mesma esteira o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente" (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Por fim, ficou devidamente caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, eis que o tráfico era cometido nas imediações de uma instituição de ensino.

Não é demais anotar que, para a incidência da majorante prevista no inciso III do art. 40, da Lei 11.343/06, não é necessário que o agente vise a difusão do entorpecente entre frequentadores da escola, bastando que o delito se pratique no local ou em suas imediações, porque o objetivo da lei é impedir, no máximo, a propagação da toxicomania em locais de maior concentração popular.

Nesse sentido, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação nº 0320753-56.2010.8.26.0000, de que foi Relator o E. Desembargador JUVENAL DUARTE: "E não há como desconsiderar que a causa de aumento em exame é de natureza objetiva, irrelevante, portanto, para a sua configuração, indagar se o autor do crime visava comercializar ou fornecer drogas aos frequentadores desses estabelecimentos públicos, pois a lei exige tão somente que o tráfico ocorra nas imediações desses locais, porquanto, é inegável, o fluxo e a concentração de pessoas nesses sítios facilitam a ação de traficantes e a prática ilícita, dificultando a ação policial, evidenciando que o dano à saúde pública se potencializa exponencialmente".

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu reincidente (fls. 108/116). Entretanto, essa circunstância só pode ser considerada

na segunda fase de fixação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da pena, está presente a agravante da reincidência, inclusive específica (autos 0015930-78.2014, 1501457-78.2019 e 1501870-91.2019, todos da 2ª Vara Criminal local, e autos 1509579-05.2020 desta 4ª Vara Criminal – fls. 108/116), razão pela qual aumento a pena fixada em um quinto, resultando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Prosseguindo, presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, elevo a pena em um sexto, resultando sete anos de reclusão e setecentos dias-multa. Reincidente o acusado, descabe a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do art. 33 do referido diploma legal.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência específica e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: “Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual”. (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar” (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.). Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré GUSTAVO DOS SANTOS VICENTE, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, “caput”, c.c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário”.

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 12/12/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]